

1500946-77.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... - local da abordagem é ponto de tráfico de drogas e nervosismo do acusado - os guardas municipais entenderam que havia fundada suspeita para realizar a abordagem pessoal, que resultou na apreensão das porções de drogas, em consonância com o dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500946-77.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2239069/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 20002553 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

3397/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2239069 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA,

3397/21/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JAMES ANDRE DOS SANTOS BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

JAMES ANDRÉ DOS SANTOS BARROS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 01 de setembro de 2021, na rua São Marcos, nº 119, Cruzeiro, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, com a finalidade de comércio, 02 porções de maconha, 3 porções de cocaína e 03 porções de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 130/131.

Recebida a denúncia aos 13 de janeiro de 2022 (fl. 138), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fls. 169 e 184) e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 169).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 196/204).

A defesa, postulou, preliminarmente, a nulidade ab initio do procedimento embasada na ilicitude da abordagem realizada pelos guardas municipais, a par da abordagem realizada por simples suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, requerendo, ainda, sua desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 207/214).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente não assiste razão a defesa quanto às questões cogitadas em preliminar.

O art. 244 do CPP preconiza que a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso, diante das circunstâncias elencadas - local da abordagem é ponto de tráfico de drogas e nervosismo do acusado - os guardas municipais entenderam que havia fundada suspeita para realizar a abordagem pessoal, que resultou na apreensão das porções de drogas, em consonância com o dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Ainda, diferentemente do acenado, descabido falar-se, na espécie, em prova ilícita, mercê da conduta dos guardas municipais. Isto porque não se vislumbrou durante a execução da prisão ação que ultrapassasse as raias das funções que os agentes municipais estão autorizados a exercer.

Embora o texto da Constituição Federal que prevê a possibilidade da constituição da guarda municipal explicita que sua função consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do Município (artigo 144, parágrafo 8º), isto não significa que seus integrantes não ostentem a condição de agentes da autoridade, até porque o dispositivo acha-se inserido e há que se atentar para a interpretação sistemática, que sobreleva àquela puramente gramatical no capítulo da segurança pública.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que os guardas municipais estão " legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do Código de Processo Penal ". E " se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime " (RHC nº 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).

No mesmo sentido, " não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo " (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade em razão da prisão e apreensão das drogas ter sido feita por guardas municipais. Inconsistência. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha.

Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 3. O grau de culpabilidade da conduta e a reincidência justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade e obstam a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além da própria quantidade da sanção. 4. Penas inalteradas. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00228073920148260320 SP 0022807-39.2014.8.26.0320, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/06/2016)

Apelações. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos réus como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Recursos da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Situação de flagrante delito que justificava a prisão dos réus. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Penas inalteradas. Apelos improvidos. (TJ-SP - APL: 00137352120158260602 SP 0013735-21.2015.8.26.0602, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 16/03/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJ-SP - APL: 00014730920168260536 SP 0001473-09.2016.8.26.0536, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/10/2018)

HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal - Ilícitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva - Prova Ilícita - Falta de Justa Causal - Trancamento da Ação Penal - Não Verificado - Art. 301 do CPP - Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão - art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data

de Publicação: 02/12/2015).

No mérito, a materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 106/114) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína e maconha, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a propriedade da droga apreendida, argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal.

James declarou que naquela ocasião retornava de seu curso quando resolveu ir até a rua São Marcos para comprar maconha e cocaína. Contou que naquele local se encontrou com Suzane e começaram a conversar, bem como decidiram consumir drogas conjuntamente. Quando seguiam para a sua casa decidiram “bolar um baseado”, momento em que foram surpreendidos pela viatura da Guarda Municipal.

Por outro lado, os guardas municipais que apreenderam a droga relataram que na ocasião dos fatos realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram o acusado e uma mulher. Contaram que quando ele notou a presença da viatura, demonstrou nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Realizada revista pessoal, com ele apreenderam algumas porções de entorpecente.

Indagado sobre os fatos, o acusado teria admitido a traficância.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

O Guarda Municipal Wagner relatou que somente abordou o acusado porque ele apresentou um certo nervosismo quando dele se aproximou, a par de que ele se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Disse que realizada sua revista, apreendeu em seu poder algumas porções de maconha, crack e cocaína. Por fim, salientou que embora uma mulher estivesse na companhia do acusado, ela não foi identificada, tampouco conduzida à Delegacia de Polícia. Ao final, informou que não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais.

Por sua vez, o GM Cleber, além de atestar o encontro de drogas em poder do acusado, salientou que a “moça” que o acompanhava mencionou que estava no local apenas conversando com o acusado.

Pontue-se que, não obstante houvesse uma pessoa ao lado do acusado que teria presenciado a abordagem realizada pelos guardas municipais, ela não foi sequer identificada pelos agentes públicos, tampouco conduzida à Delegacia de Polícia.

Anote-se, que ambos os guardas mencionaram que o acusado teria admitido que ali estava realizando o tráfico de drogas. Destarte, o depoimento de referida pessoa (Suzane), que segundo os informes, acompanhou toda a abordagem do acusado, era imprescindível para esclarecer os fatos, especialmente para ratificar a versão dos guardas quanto à suposta confissão do agente.

Não se trata, aqui, de lançar um véu de suspeição sobre as palavras dos diligentes agentes públicos, que, durante patrulhamento de rotina depararam-se com o acusado e localizaram a droga.

Isto está comprovado nos autos.

O que não está demonstrado, com a certeza necessária para a fundamentação de um édito condenatório, é a destinação que seria dada ao entorpecente.

De forma que eventual condenação do acusado pelo hediondo crime de tráfico ilícito de entorpecentes teria como fundamento apenas e tão-somente a apreensão da droga.

O que não se admite, obviamente.

Lado outro, a quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, uma vez que é possível a utilização com facilidade do material apreendido (2 porções de maconha, 3 porções de cocaína e 3 porções de crack).

Assim, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando com ele a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado.

A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse com a

finalidade de uso próprio.

As várias tentativas de caracterizar a conduta do acusado como tráfico, quando há menção de que ele teria admitido informalmente aos guardas municipais de que a droga com ele apreendida estaria destinada ao comércio ilícito são genéricas demais para sustentar uma incriminação e não ostentam segurança para que o Juízo forme uma convicção segura.

Na mesma esteira, a suposta admissão do acusado em seu interrogatório policial. Ocorre que, em Juízo, James se retratou e admitiu que a droga com ele localizada era para seu consumo pessoal.

Embora este Juízo tenha entendimento que a confissão policial possui valor probatório, deve ela vir cercada por outros elementos de provas. No caso dos autos, sua confissão realizada em sede extrajudicial e depois retratada em Juízo, não detém suficiente valor probante quando verificada com as demais provas produzidas. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO APELADO - IMPRECISÃO SOBRE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O ACUSADO - DELAÇÃO DO CONDUZIDO JOÃO RETRATADA EM JUÍZO - DISCREPÂNCIA NAS DECLARAÇÕES DOS GUARDAS MUNICIPAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - APELO DESPROVIDO. A prova, para ensejar uma condenação, principalmente quando se trata de penas acerbadas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, e esta não é a hipótese dos autos, motivo por que se faz imperiosa a manutenção da sentença absolutória proferida na instância singular, em homenagem ao princípio do "in dubio pro reo". (Ap 96200/2010, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2011, Publicado no DJE 06/05/2011) (TJ-MT - APL: 00962004320108110000 96200/2010, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/04/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2011).

A par disto, não havia nenhuma denúncia anônima indicando o tráfico realizado pelo acusado ou sobre o local em que estava, em que pese os guardas municipais terem mencionado que o local era conhecido como "biqueira". Repise-se, ainda, que os agentes mencionaram que não conheciam o acusado de outras ocorrências, tampouco sabiam de eventual envolvimento no tráfico de drogas.

Acrescente-se, também, que a defesa colacionou aos autos comprovação de que o acusado exercia atividade lícita, comprovando, destarte, a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder (fls. 166/168).

Diante deste contexto, incumbindo ao Ministério Público provar de maneira absoluta a traficância, o que não ocorreu, a desclassificação é medida que se impõe.

Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos é a autoria e a materialidade deste delito. Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado.

Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o

"tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não justificam maior reprovação, razão pela qual as penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR JAMES ANDRÉ DOS SANTOS BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma dos §§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado se encontra nesta condição e não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, defiro a restituição do dinheiro e do aparelho celular apreendidos em poder do sentenciado, bem como promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA